

1502640-72.2022.8.26.0472

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502640-72.2022.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502640-72.2022.8.26.0472

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVANDRO DONIZETE DE MELO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de EVANDRO DONIZETE DE MELO, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 306, § 1º, incisos I e II, c.c art. 298, inciso III, ambos da Lei 9.503/97, afirmando que em 21 de fevereiro de 2022, por volta de 01h40min, na rua Vitório Colli, nº 554, Vila Maria, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, conduziu veículo automotor, uma motocicleta Honda/XR 200, placa CZW-4494, sem possuir habilitação e com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, "o denunciado, sem possuir habilitação para dirigir e após ter ingerido bebida alcoólica, trafegava com a motocicleta Honda/XR 200, placa CZW- 4494, pelas vias públicas desta cidade quando se deparou com uma viatura da Polícia Militar, ocasião em que empreendeu fuga em alta velocidade, não obedecendo às ordens de parada. Após breve perseguição o denunciado perdeu o controle da motocicleta e caiu, sendo então alcançado. O denunciado, que apresentava sinais característicos de embriaguez como olhos

avermelhados, odor etílico e fala pastosa, realizou o exame de alcoolemia por meio do etilômetro, sendo constatado que conduzia seu veículo com concentração de álcool igual a 0,74 miligramas de álcool por litro de ar alveolar (cf. documento à fl. 25), caracterizando a infração penal."

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O topo do artigo 306 da Lei 9.503/97 assim descreve o delito:

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência

O tipo objetivo pune a conduta de conduzir (guiar ou dirigir) veículo automotor (definição no Anexo I da lei especial) com a capacidade psicomotora alterada em razão de uso de substância psicoativa (que pode ser droga lícita ou ilícita, bastando que cause excitação psicomotora), enquanto o tipo subjetivo é doloso.

É crime de perigo abstrato, dispensando a prova de efetiva exposição do bem jurídico. É nesse sentido, inclusive, que se orientam as duas turmas do STJ com competência criminal (grifos nossos):

O crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal. Precedentes.

STJ, AgRg no AREsp 1241914/SP, Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

"A espécie, segundo entendimento iterativo desta Corte, é de crime de perigo abstrato, sendo despendida a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta do agente. Basta que esteja conduzindo veículo automotor sob a influência de álcool."

STJ, RHC 97.585/SP, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018.

O tipo, desde 12 de dezembro de 2012, não mais exige que o fato se dê em via pública; não se exige, desde 1º de novembro de 2014, a comprovação da perturbação da capacidade psicomotora por meio de etilômetro.

No caso em exame, há prova da existência do crime e de sua autoria.

A conduta do agente foi descrita de forma uniforme e coerente tanto na fase pré-processual (boletim de ocorrência de fls. 21/22) como na prova oral colhida em juízo. A alteração de sua capacidade psicomotora foi comprovada pelo teste de fls. 25.

A testemunha de acusação, o policial militar Anselmo da Silva Correa, na fase policial disse que "nesta madrugada, juntamente com o colega de farda "Estefano", realizavam patrulhamento pelo Bairro Vila Maria quando avistaram, na Rua Batista Arnoni, um motoqueiro em atitude suspeita e decidiram pela abordagem, não tendo o mesmo obedecido ao sinal de parada e se evadido em alta velocidade; que durante rápido acompanhamento, mais precisamente na Rua Vitória Coli, altura do numeral 554, Vila Maria, o suspeito caiu da motocicleta e, nessa oportunidade, foi abordado e identificado como Evandro Donizete de Melo; que durante revista pessoal nada de ilícito foi encontrado em poder do Indiciado; que solicitada a documentação da motocicleta constatarem que a mesma, uma Honda, modelo XR 200R, placas CZW 4494, estava em ordem; que também foi solicitado ao Indiciado apresentação de sua CNH,

tendo ele alegado não ser habilitado; que o Indiciado apresentava características de embriaguez, como olhos vermelhos, fala pastosa e hálito etílico, o que motivou a ser convidado para realização do teste do etilômetro; que, aceito o convite, o Indiciado realizou o teste do bafômetro, tendo o resultado do exame indicado concentração de 0,74 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expirado; que ante esses fatos o policial "Estefano". Em juízo manteve sua versão. Acrescentou que abordaram porque o motorista estava ziguezagueando. Disse que Evandro tinha olhos vermelhos, falta de equilíbrio, fala alterada e odor etílico, além de roupa desalinhada; etilômetro constatou embriaguez; nome dele não constava como condutor habilitado.

A testemunha de acusação, o policial militar Abrão Estefano Amaro de Souza, na fase policial disse que "nesta madrugada, juntamente com o colega de farda "Anselmo", realizavam patrulhamento pelo Bairro Vila Maria quando avistaram, na Rua Batista Arnoni, um motoqueiro em atitude suspeita e decidiram pela abordagem, não tendo o mesmo obedecido ao sinal de parada e se evadido em alta velocidade; que após rápido acompanhamento, mais precisamente na Rua Vitória Coli, altura do numeral 554, o suspeito caiu da motocicleta e, nessa ocasião, foi abordado e identificado como Evandro Donizete de Melo, nada de ilícito tendo sido encontrado em seu poder; que solicitada a documentação da motocicleta constataram que a mesma, uma Honda, modelo XR 200R, placas CZW 4494, estava em ordem; que solicitada a apresentação de sua CNH, o Indiciado alegou não ser habilitado; que, em virtude do Indiciado apresentar características de embriaguez, como olhos vermelhos, fala pastosa e hálito etílico, o convidaram para realização do teste do etilômetro, o que foi aceito, tendo o resultado do exame indicado concentração de 0,74 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expirado." Em juízo manteve sua versão. Disse que Evandro dirigia rapidamente e ziguezagueando e por isso fizeram a abordagem. Evandro tinha fala pastosa, odor etílico, falta de equilíbrio, ofereceram o etilômetro. Explicou que ele poderia se recusar e poderia fazer o teste clínico no hospital. Evandro aceitou o etilômetro. Lembra que havia irregularidade quanto à condução, mas não lembra qual.

EVANDRO DONIZETE DE MELO, em declarações perante a autoridade policial disse que "se reserva no direito de permanecer calado e somente reportar-se aos fatos em Juízo." Em juízo disse estava alcoolizado, que os PMS disseram que o exame era facultativo, que havia bebido duas latinhas de cerveja.

Independentemente de o acusado ter confessado os fatos, a prova oral trazida pela acusação foi uniforme e coerente, amparada por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Configurado o delito de embriaguez ao volante, cujo preceito secundário prevê pena de "detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor".

Passo a dosar as penas.

Ressalto que a fixação dos aumentos da primeira fase sobre a pena mínima constitui procedimento contrário à lei. Apesar disso se aplicar a qualquer tipo penal, a contrariedade é notada mais facilmente nos casos em que há grande intervalo entre a mínima e a máxima, quando esta se torna impossível, frustrando a determinação do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima gera outra injustiça. Percebe-se que em alguns casos a qualificadora somente aumenta a pena máxima; é o que ocorre, a título de exemplo, com a lesão simples no âmbito da violência doméstica. Ora, calcular os aumentos tendo por parâmetro a pena mínima é

ignorar o comando legal que deu especial gravidade ao delito cometido naquela situação específica.

Sem contar os casos em que o intervalo de pena é menor que a pena mínima (§3º do art. 302 da Lei 9.503/97, artigos 267, 270 e 273 do Código Penal, entre outros), quando a utilização somente desta causa considerável prejuízo ao réu.

As situações e razões aqui trazidas são suficientes para demonstrar que a fixação da pena na primeira fase levando em conta somente a pena mínima contraria a lei e o sistema de imposição de sanções por ela previsto.

Ora, como o legislador estabelece sempre um mínimo e um máximo, ambos são a medida legal da gravidade do delito, de modo que o procedimento mais adequado para perceber essa grandeza em sua inteireza é levar em consideração justamente o intervalo de pena, ou seja, a diferença entre o máximo e o mínimo legal; aplica-se o aumento sobre o intervalo, adicionando a pena mínima.

É o que recentemente vem fazendo o STJ:

Considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista para o delito de sonegação fiscal e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afigura desarrazoada ou desproporcional a exasperação da base em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal, porquanto, na compreensão das instâncias ordinárias, suficiente à prevenção e reprovação do crime.

STJ, AgRg no AREsp 1194509/MG, Quinta Turma, rel. Min. José Ilan Paciornik, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

A gravidade concreta do delito, praticado por pessoa que é integrante da polícia militar e que mais do que qualquer outro servidor público deve primar pela respeitabilidade de sua instituição e preservar o pundonor que rege a caserna; bem como o modo de execução, tratando-se de delito praticado por meio de grave ameaça e violência moral, justificam a fixação da pena-base 2 anos acima do mínimo legal, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, que vai de 2 anos a 8 anos de reclusão.

STJ, AgRg no REsp 1678420/PA, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018.

Descabe falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela culpabilidade, pois, considerando a fração de aumento ideal de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento da reprimenda em 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora, ou seja, em patamar inferior ao estabelecido no decreto condenatório.

STJ, HC 448811/PR, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

Quanto aos maus antecedentes, descabe falar em desproporcionalidade no aumento da pena em 6 meses, considerando a presença de dois títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, assim como o intervalo do apenamento estabelecido no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

STJ, HC 451487/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018.

Mantém-se a valoração negativa das vetoriais analisadas pelo v. acórdão impugnado, tendo em vista a fundamentação concreta apresentada, descabendo falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão, considerando o critério ideal de aumento por circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 6 anos.

STJ, HC 446462/SP, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

É também a posição do Plenário do STF:

Ausente a alegada desproporcionalidade entre os parâmetros utilizados na dosimetria das penas dos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, sobretudo porque se tratam de delitos cujas objetividades jurídicas são distintas e que apresentam diferentes intervalos penais nos respectivos preceitos secundários.
AP 470 EDj-sétimos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 05/09/2013, DJe 10/10/2013.

Não se aplica um critério meramente matemático de comparação entre penas cominadas a delitos distintos, com intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de violação do princípio da individualização.
AP 470 EDj-vigésimos quartos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 28/08/2013, DJe 10/10/2013.

Aliás, em ações de competência originária das cortes superiores a dosimetria no intervalo da pena é uma constante.
Por exemplo, nos dois títulos penais condenatórios emitido pela Suprema Corte em 2019 (AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019, e AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020) nota-se claramente este procedimento (grifos nossos - diversos do original):

13.a.1) Quanto ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de três anos de reclusão e máxima de doze anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

13.b.1) Relativamente ao crime de empréstimo vedado (art. 17 da Lei 7.492/1986) (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de dois anos de reclusão e máxima de seis anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019.

No juízo de individualização da pena à luz do caso concreto, anoto que a sanção cominada de forma abstrata ao crime de lavagem de dinheiro é de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, nos termos do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998.
(...) fixo-lhe a pena-base, para cada delito de lavagem de dinheiro, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.
AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020.

A dosimetria foi adotada por unanimidade pelos dois colegiados, conforme extratos de ata.

Não diverge a Segunda Turma do Pretório Excelso. Na condenação em ação penal originária (AP 644/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 16/03/2018) assim se pronunciou:

(...) deve-se observar as penas originalmente cominadas, “reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa” (...) Considerando a particular gravidade das circunstâncias mencionadas, estabeleço a pena-base em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Em sentido idêntico a Corte Especial do STJ (APn 327/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2018, DJe 19/12/2018):

Os fatos narrados ajustam-se aos elementos configuradores do delito de peculato-desvio (art. 312, 2ª parte do Código Penal). (...) Portanto, diante destas três circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Assim, sopesadas tais circunstâncias e observadas a razoabilidade e a proporcionalidade da reprimenda para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Observar no voto acima que o aumento na pena corporal é idêntico ao da pena de multa, caso se considere o intervalo das penas (30% dos intervalos).

Tampouco se faz aqui tarifação de aumentos em tabelas predeterminadas. Além de não haver respaldo legal, isso fere de morte o espírito do Código Penal que estimula a valoração concreta dos elementos do caso.

Não se há falar em tabelamento das reprimendas, nem mesmo em institucionalização da pena mínima.

TJSP, Apelação n. 0000142-53.2017.8.26.0472 , 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Costabile e Solimene, j. 23.08.2018.

Preambularmente, lembro que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base.

AP 996/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018, DJe 08/02/2019.

Segundo o procedimento que valora cada circunstância judicial com um aumento de 1/6 ou 1/8, merecerá a reprimenda máxima o fato criminoso em que estiverem presentes todas as circunstâncias, pouco importando as suas gravidades, ao passo que um fato criminoso envolto em somente uma circunstância negativa, mas presente em um grau absurdo, sofrerá um aumento mínimo.

Ora, isso é uma má interpretação sobre o sistema de imposição de penas estabelecido pela Reforma de 1984 e um descumprimento da Constituição na medida em que esta impõe a individualização da pena, a qual necessita uma valoração da gravidade concreta das circunstâncias, e o art. 59 do Código Penal exige que a fixação da pena atenda à finalidade de reprovação e prevenção do crime, o que também não se alcança com tabelamentos.

Como diz Roberto Lyra nos seus comentários ao Código Penal, a adoção de um sistema de penas inflexíveis estabelece uma igualdade que é a pior das iniquidades. E continua, "a rigor, há arbítrio na lei, no seu apriorismo, na sua abstração, na sua dureza. Nas mãos dos juízes, o texto deixa de ser arbítrio, humanizando-se, sensibilizando-se, adaptando-se à vida e à personalidade de cada homem. Portanto, é a lei que renuncia ao seu egoísmo e vai palpitar, ao ritmo flagrante do convívio social, através da toga. Os mandamentos legais são frios e autoritários. Para o homicídio – de 12 a 30 anos. Por quê? Para quê? Com a liberdade dos juízes responsáveis, não somente em atenção a circunstâncias convencionalmente enumeradas, e sim à realidade integral de cada homem e de cada fato". Para ele, "enquanto se mantiver, com a seleção moral e intelectual, a independência da magistratura, o arbítrio judicial, regulado cautelosamente, como fez o Código, só poderá ser salutar".

Deste modo, o magistrado que fixa os aumentos levando em conta somente o número de circunstâncias e não a suas valorações concretas, age com um automatismo que leva à injustiça e faz pouco de sua toga.

Portanto, o grau do aumento depende mais da intensidade concreta das circunstâncias que da extensão com que são encontradas.

Não se nega, contudo, que alguns julgadores ainda se valem do antigo método da pena mínima e do tabelamento de aumentos. Todavia, agindo contra toda a jurisprudência dos tribunais superiores, é dever justificar a heterodoxia.

Primeira etapa. Na análise das circunstâncias judiciais, nas quais são preponderantes a culpabilidade do agente, as circunstâncias e consequências do crime (§4º do art. 291 da Lei 9.605/97), anoto que, embora a infração penal seja de perigo abstrato, a pessoa imputada dirigiu de forma perigosa na condição de embriaguez, inclusive desrespeitando ordem de parada da polícia e causando sua queda. Estas circunstâncias, nitidamente, não estão ínsitas ao tipo e ensejam uma reprimenda de um terço sobre o intervalo de pena.

Fixo a pena-base em um ano e dois meses de detenção, além de 126 dias-multa.

Segunda etapa. Presente a agravante do inciso III do art. 298 da Lei 9.605/97. Presente também a atenuante da confissão. Faço a redução para um ano e 25 dias de detenção, além de 115 dias-multa.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena.

Tratando-se de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, sem caráter hediondo, de condenado não reincidente e com pena inferior a quatro anos, fixo como inicial o regime aberto.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR EVANDRO DONIZETE DE MELO à pena de detenção, pelo prazo de um ano e 25 dias, em regime inicial aberto, bem como a 115 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no topo do artigo 306 da Lei 9.503/97.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (§2º do art. 44 do Código Penal) conforme determinação do juízo da execução e as diretrizes do art. 312-A do Código de Trânsito.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 10 de agosto de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

Cópia dessa sentença assinada digitalmente servirá como ofício.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA